

دلال الرزوقي

باحثة بسلك الدكتوراه

إشراف الأستاذة الدكتورة سلمى شكري

مختبر القانون الخاص - كلية العلم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكد
جامعة محمد الخامس بالرباط

التوفيق بين حماية المالك الحقيقي للعقار والغير المقيّد

عن حسن نية بالرسم لعقاري

تعليق على قرار لمحكمة النقض بمجموع غرفها عدد 2/36 المؤرخ في 2017/1/17 بالملف
مدني عدد 15209/2/2012

Balancing the protection of the real owner of the property and the person who is not registered in
good faith with the real estate registration

أهلا: النص الكاهل للقرار⁷¹²

محكمة النقض بمجموع غرفها - قرار عدد 2/36 المؤرخ في 2017/01/17 ملف مدني عدد
2012/2/1/5209.

الحمد لله، باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 2017/01/17 إن محكمة النقض بمجموع غرفها في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي
نصه: بين [ح.ش.ض] الساكن ب... طنجة، ينوب عنه الأستاذ [م.ق.] المحامي بهيئة الرباط والمقبول
للترافع أمام محكمة النقض، الطالب. وبين شركة [د.] شركة مجهولة الاسم، في شخص ممثلها
القانوني، مقرها ... طنجة، ينوب عنها الأستاذ [ز.ع.ز] المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام
محكمة للنقض، المطلوبة، بحضور السيد [ح.ق.ض] الساكن ب... طنجة.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2012/11/27 من طرف المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ
[م.ق.] الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 790 الصادر بتاريخ 2012/7/25 في الملف
عدد 4/04/722.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2013/3/11 من طرف المطلوب ضدها النقض
بواسطة نائبا الأستاذ [ز.ع.ز] والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2016/10/24.

712) نشرته محكمة النقض ضمن مجموع قرارات محكمة النقض بغرفتين أو بمجموع الغرف؛ ونشرته في موقع البوابة
القضائية للملكة المغربية، ونشره الأستاذ الدكتور أحمد ادريوش ضمن مؤلفه مناهج القانون العقاري المعمق، منشورات
سلسلة المعرفة القانونية، مكتبة دار السلام، الإصدار رقم 41، 2023، ص.335

وبناء على قرار السيد الرئيس الأول عدد 2014/11 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2014 والقاضي بإحالة الملف موضوع النازلة على هيئة قضائية مكونة من غرفتين وان تضاف الغرفة الجنائية (القسم الرابع) إلى الغرفة المدنية (القسم الثاني) المعروضة عليه القضية.

وبناء على القرار الصادر عن الغرفتين بتاريخ 2014/04/08 والقاضي بإحالة القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2016/12/06.

وبناء على المندادة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ [م.ق.] عن طالب النقض.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر.

وبعد المرافعة الشفوية للأستاذ [م.ق.] التي أكد فيها ما ورد في عريضة النقض وأكد على أن الطاعن حسن النية، وأنه تم تبرئته من جريمة استعمال محرر رسمي مزور وأن القرار المطعون فيه اعتمد قاعدة منطقية وهي ما بني على الباطل باطل ولم يطبق الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري الواجب التطبيق على القضية والتمس نقض القرار.

وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الم رابط الرامية إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقاً للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2012/7/25 تحت عدد 790 في الملف عدد 4/722، أن المطلوبة في النقض "شركة [د]" تقدمت بتاريخ 2003/09/11 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيها أنها تملك العقار ذا الرسم العقاري عدد G/317 الملك المسمى [س.إ.غ.] وأنها فوجئت بتسجيل رسم عدلي مؤرخ في 2003/3/12 بهذا الصك بتاريخ 6 مارس 2003، مفاده أن شركة [د] أجرت مبادلة بينها وبين [ح.ق.ض.]، كما تم في نفس اليوم تسجيل بيع كلي موضوع عقد عرفي بين [ح.ق.ض.] والطاعن [ح.ش.ض.] مؤرخ في 2002/8/5، وأنه بعد مراجعة الوثائق بالمحافظة العقارية تبين أن الرسم العدلي موضوع المبادلة لم يبرم في 2003/3/12 وإنما تم تحريره بتاريخ 1960/8/12، كما اتضح أن عقد المبادلة يفتقد لعدة شروط وتنقصه مجموعة من البيانات الجوهرية وتعتبره غير ملزم ها خصوصاً وأن الأمر يتعلق بعقار محفظ مملوك لشركة أسهم لا يمكن التصرف فيه إلا بناء على قانون الشركات والقانون الأساسي للشركة المعنية. كما أن البيع المبرم بين [ح.ق.ض.]، و[ح.ش.ض.] غير صحيح لبنائه على فاسد، والتمست التصريح بعدم صحة رسم المبادلة المحررة في 1960/8/12، وعقد البيع المبرم بين المدعى عليهما [ح.ق.ض.] و[ح.ش.ض.] والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بالتشطيب على القيدتين المسجلين بالصك العقاري عدد G/317 بتاريخ 6 مارس 2003، كناش 142 عدد 425 وكناش 142 عدد 426. وبعد جواب المدعى عليه [ح.ش.ض.] بأن الدعوى غير مقبولة لعدم توجيهها ضد السيدين جورج بلازاك، وإدوار كوري ولا ضد ورثتها، وأن رسم المبادلة المطعون فيه ابرم في 10 محرم 1381 أي منذ أزيد من 43 سنة مما يجعل دعوى طلب إبطاله ساقطة بالتقادم، كما أن رسم المبادلة المذكور تضمن قول العدلين "عرفا قدره شهد به عليهما بأتمه وعرف بهما" مما يجعلها شهادة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور بعد أن خاطب عليها القاضي المختص، وأن الأصل في العقود الصحة،

ورسم المبادلة موضوع النزاع مسجل ومضمن بسجل المختلفة عدد 89، وأن المشتري [ح.ش.ض.] أجنبي عن هذا العقد، وأنه مشتر حسن النية، لا يمكن بأي حال التمسك بإبطال التقييد في مواجهته ويبقى شراؤه صحيحا مادام قد أبرم مع شخص مقيد بالمحافظة العقارية، كما أنه لا عبء لمدة التقييد مادام هذا التقييد يدل على أن المقيد هو المالك. وجواب المدعى عليه [ح.ق.ض.] بأن رسم المبادلة العدلي المبرم بينه وبين المدير العام لشركة [د] السيد ادوار كوريير المنجز بتاريخ 10 محرم 1381 وموضوعه مبادلة القطعة الأرضية المملوكة للشريكة بالقطعة الأرضية الواقعة بحجر النحل المملوكة لـ [ح.ق.ض.] هو عقد صحيح، وأن الخلاف الوارد في السند العقاري بالنسبة لتاريخ المبادلة وهو 2003/3/12 بدل تاريخه الحقيقي الذي هو 1960/8/12 لا اثر له، وأن العدلين عرفا في رسم المبادلة بالمسمى جورج بلازوك الذي حضر مجلس العقد بكونه هو الكاتب العام بالمحكمة المختلطة وهو تعريف كاف وشامل، وأن الطعن في عدم أهلية مدير الشركة في التصرف لا أساس له. وأن عدم التعريف بالترجمان ادعاء خاطئ لأن العدلين توجهها لدى الموظف بالمحكمة المختلطة المسمى بلازوك من أجل القيام بعملية الترجمة، كما أن تأخر المتعاقد عن تسجيل التفويت ليس من شأنه أن يسقط حقه التسجيل، كما أن تسجيل التصرف الثاني بين [ح.ق.ض.] و [ح.ش.ض.] لا يمكن أن يطلاله أي إبطال لأنه يكتسي حجية قطعية طبقا للمادة 66 ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والتمسا رفض الطلب، وصدر حكم ابتدائي بتاريخ 2004/3/25 في الملف عدد 03/1945 تحت عدد 4/754 برفض الطلب؛ وألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم صحة الرسم المبادلة المحرر في 1961/6/25، وكذا البيع المبرم بين المستأنف عليهما [ح.ق.ض.] و [ح.ش.ض.] بتاريخ 2002/8/22 والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بالتشطيب على القيدتين المتعلقين بهما والمسجلين بالصك العقاري عدد G/317؛ وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف [ح.ش.ض.]

فيما يتعلق بالفرع الأول من الوسيلة الأولى

حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل، ذلك أنه تمسك بأن رسم المبادلة الذي بموجبه تملك البائع له العقار موضوع النزاع يعود إلى وقت سابق عن تاريخ الادعاء بمدة تفوق 43 سنة مما يجعل الدعوى قد طالها التقادم، إلا أن القرار لم يجب عما أثاره هذا الشأن.

لكن، حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي يتم التمسك بها أمامها ويكون لها تأثير على قضائها، والبين من مذكرتي الطاعن المؤرختين في 2005/2/15 و 2008/11/25 أن الطاعن لم يثرو لم يتمسك بالدفع بالتقادم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مما لا يعاب معه على المحكمة عدم الجواب على دفع لم يتم التمسك به صراحة أمامها إضافة إلى أن من لم يصح له التقادم المكسب لا يستفيد من التقادم المسقط ولذلك فإن ما بالفرع من الوسيلة على غير اساس.

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الأول والثاني والثالث والرابع من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة.

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مبدأ عدم رجعية القوانين وفساد التعليل وخرق الفصلين 66 من ظهير التحفيظ العقاري و3 من ظهير 1915/6/2 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة والفصل 1 و345 من ق.م.م و230 من ق.ل.ع، ذلك أنه اعتمد، وخلافا للنصوص

القانونية الصريحة والواضحة المستدل بها، على أن عمل محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)، استقر منذ سنة 2007 على أن حماية المالك أولى من حماية المشتري، وهذا الموقف، حتى ولو أعطيت له القوة المعطاة لنصوص القانون، لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي على وقائع وعقود حررت وأبرمت قبل تقرير الاجتهاد المذكور بمدة تفوق 64 سنة؛ كما أنه تمسك بأنه اشترى العقار بحسن نية وفي وقت لم يكن الرسم المذكور مثقلا بأي حجاز أو تقييد احتياطي أو أي تحفظ آخر من شأنه أن يبعث الشك في جدية تملك البائع الذي وإن كان محل متابعة وإدانة، فإن القرار الجنائي القاضي بإدانتته قضى ببراءته هو، وهذه حجة على حسن نيته وأن حسن النية مفترض دائما؛ غير أن القرار لم يرد على ذلك، واكتفى بمجرد القول: إن الزور لا ينتج أي أثر، وأن ما بني على باطل فهو باطل. وهو أمر لا ينطبق على حاله لكون شرائه مبنيا على شراء صحيح وليس على شراء باطل، وأن القاعدة المذكورة هي مجرد قاعدة منطقية عامة يعارضها نصوص قانونية صريحة، لأن القرار عندما استبعد تطبيق الفصلين 66 من ظهير التحفيظ العقاري و3 من ظهير 1915/6/2 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة لم يبين النص الواجب التطبيق بدل تلك المستبعدة، ولم يرد على ما تمسك به من أنه لا اجتهاد مع وجود النص، وعدم جواز تدخل القضاء في سلطات المشرع لأنه يمنع على المحاكم، عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة، أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها، كما أنه لا يجوز للجهات القضائية البت في دستورية القوانين وأن القرار عندما تجاوز نصوصا قانونية واعتمد قاعدة منطقية مما يجعله خاضعا للجزاء المقرر في الفصول 25 - 9 - 382 من ق.م.م.

لكن، حيث إنه، وطبقا للفصلين 66 من ظهير التحفيظ العقاري و3 من ظهير 1915/6/2 بشأن التشريع المطبق على القرارات [كذا في نسخة القرار، وهو خطأ مطبعي والصحيح هو "العقارات"] المحفظة، وبمقتضاهما "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية. ولا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة"؛ ولما كان الغير المسجل عن حسن نية لا يمكن التمسك بإبطال التسجيل في مواجهته عملا بالفصلين 66 و3 المذكورين، فإن الغير السيء النية هو من كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم عيب سند سلفه؛ والطاعن لا يمكن اعتباره حسن النية، اعتبارا لوقائع النزاع الثابتة بالقرار الجنائي الذي يعد حجة على ما يثبتته من وقائع عملا بالفصل 418 من ق.ل.ع، فالطاعن ماقول، ويتاجر في العقارات ويفترض فيه الحذر في معاملاته، وقد اشترى العقار بتاريخ 2003/3/6 بثمن لا يلائم قيمته وهو مسجل باسم الشركة المالكة [د]، كما اعتمد في البيع على مبادلة يعود تاريخها لسنة 1961 غير مسجلة بالرسم العقاري رغم مرور أكثر من أربعين سنة على تاريخها، كما سجل عقد البيع والمبادلة في يوم واحد، وهي قرائن قوية ومتعددة على أن الطاعن كان في إمكانه أن يعلم العيب الذي يشوب المبادلة المستند عليها في التملك من طرف البائع له، وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تستبدل محكمة النقض علة القرار المنتقدة، مما يبقى معه ما أثير في أسباب النقض أعلاه غير مبني على أساس.

فيما يتعلق بالفرع الخامس من الوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، ذلك أن القرار استجاب لطلب تشطيب لم يقدم إلا بعد أزيد من 43 سنة من إنجاز التصرف المؤسس عليه التقييد محل طلب التشطيب.

لكن حيث إن عقد المبادلة وعقد البيع قد سجلا بالمحافظة في 2003/3/6 وقد ورفعت دعوى طلب إبطالهما في 2003/9/11 وصدر الحكم الابتدائي في 2004/3/25، ولذلك فإن المحكمة لم تطبق المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية مما لا مجال معه للتمسك بخرق مقتضياتها وببقى ما أثير بهذا الفرع غير جدير بالاعتبار.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن المصاريف.

به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد ابراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا للجلسة، والسادة مليكة بامي رئيسة الغرفة المدنية، عبد الرحمان المصباحي رئيس الغرفة التجارية، عبد المجيد بابا اعلي رئيس الغرفة الإدارية، مليكة ابن زاهر رئيسة الغرفة الاجتماعية، الطيب انجار رئيس الغرفة الجنائية، عبد الرحمان انويدر مقرر، حسن بوشامة، سعيد الروداني، عبد الرحيم سعد الله، محمد بنزهة، عمر ملين، عبد الغني العيدر، محمد عصبية، عبد الإله حنين، سعاد الفرحاوي، بوشعيب متعبد، خديجة العزوزي الادريسي، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، المصطفى الدحاني، عبد الرحمان مزوز، مربة شيحة، أنس لوكيلي، العربي عجابي، عبد العزيز سدار، محمد لحفايا، بوشعيب بوطربوش، المصطفى هמיד، جمال سرحان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد لمرباط وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

ثانيا: التعليق على القرار

تتلخص وقائع هذه النازلة، التي صدر فيها القرار قيد التعليق، في أن الشركة "إي" تقدمت بتاريخ 2003/09/11 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيه بأنها تملك العقار ذو الرسم العقاري عدد 317/G وأنها فوجئت بتسجيل رسم عدلي مؤرخ في 03/12/2003 بهذا الصك بتاريخ 6 مارس 2003، يتعلق بمبادلة بينها وبين "أب" وأنه تم في نفس اليوم تسجيل بيع كلي موضوع عقد عرفي بين "أب" والطاعن "أ ش ص"، ملتزمة التصريح بعدم صحة رسم المبادلة وعقد البيع وكذا الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بالتشطيب على القيد المسجلين بالصك العقاري وذلك بعلة أن الرسم العدلي موضوع المبادلة لم يبرم في 2003/03/12 بل تم تحريره في 1960/08/12، وأنه يفتقد لعدة شروط وتنقصه مجموعة من البيانات الجوهرية.

وبتاريخ 2004/03/25 صدر الحكم الابتدائي برفض الطلب. ألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم صحة رسم المبادلة المحرر في 1961/06/25 وكذا البيع المبرم بين المستأنف عليها والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على القيد. وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض،

بحيث عاب عليه انعدام التعليل، وأن القرار فيه خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين وخرق للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري و الفصل 3 من ظهير 1915/6/2، غير أن محكمة النقض لم تستجب لما تمسك به الطاعن وقضت برفض الطلب، بعلّة أن الطاعن لم يتمسك بالتقدم أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، وأنه لا يمكن اعتبار الطاعن حسن النية لكونه مقلد ويتاجر في العقارات ويفترض فيه الحذر في معاملاته، وأنه اشترى العقار بثمن لا يلائم قيمته وهو مسجل باسم الشركة المالكة، كما اعتمد في البيع على مبادلة يعود تاريخها لسنة 1961 غير مسجلة في الرسم العقاري رغم مرور أكثر من أربعين سنة، كما سجل عقد المبادلة والبيع في نفس اليوم وهي قرائن قوية ومتعددة على أن الطاعن سيء النية.⁷¹³

مما سبق يتضح أن الإشكالية الأساسية في هذا القرار تتمحور حول:

إلى أي حد يمكن الاعتداد بمبدأ حسن النية إذا كانت التصرفات العقارية المبرمة قائمة على عقد باطل؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات أهمها: هل تصح العقود الباطلة بتسجيلها في الرسم العقاري من قبل الغير المقيد حسن النية؟ وما هي المعايير التي يمكن من خلالها استخلاص حسن النية من سوءها؟

وعليه سنقوم بالتعليق على هذا القرار من خلال تحليل موضوعي، ومن خلال قراءتنا لهذا القرار وغيره من القرارات ذات الصلة، اتضح لنا أن الاجتهاد القضائي أخذ اتجاهات يمكن تقسيمها إلى ثلاث.

الاتجاه الأول: ترجيح مصلحة الغير حسن النية.

الاتجاه الثاني: ترجيح مصلحة المالك الحقيقي.

الاتجاه الثالث: القرار قيد التعليق هو محاولة غير مكتملة لتوحيد الاجتهاد القضائي.

الاتجاه الأول:

ترجيح مصلحة المالك الحقيقي

إن الأصل في ظهير التحفيظ العقاري وعلى الخصوص الفصل 66 منه هو عدم التمسك بإبطال أي تقييد في الرسم العقاري في مواجهة الغير المقيد عن حسن النية. لكن الواقع العملي وما يطرحه من دعاوى أمام القضاء أسفر عن إصدار مجموعة من القرارات خرجت عن القاعدة القانونية الواردة في الفصل المذكور فيما يتعلق بالتقييدات المبنية على سندات مزورة، حيث منحت الحماية الأولى للمالك الحقيقي للعقار على خلاف الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري الذي منح حماية مطلقة للغير حسن النية، وهو ما تم تجسيده في ظل المستجدات العقارية.

حيث حاول المشرع العقاري المغربي من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية خلافاً للمادة 3 من ظهير 2 يونيو 1915 الملغى والفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري أن يسلك طريقاً وسطاً بين المالك الحقيقي للعقار الذي يمكن أن يكون ضحية تدليس أو تزوير وبين الغير المقيد عن حسن النية، وذلك من خلال اشتراط المشرع على المالك الحقيقي بأن يرفع

(713) عرفت محكمة النقض في هذا القرار قيد التعليق الغير سيئ النية "هو الذي كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم العيب الذي يشوب سند أو رسم من تلقى الحق عنه".

دعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه. والهدف من هذه المادة هو مواجهة الاستعمال السيئ لحجية التقييدات، أما في حالة ما إذا كان المقيد سيئ النية فلا مجال هنا لتطبيق مقتضيات المادة الثانية لكونها تتحدث عن حسن النية. ولعل السبب وراء جعل الغير حسن النية في المرتبة الثانية في الحماية هو محاربة ظاهرة الاستلاء غير المشروع للعقارات المملوكة للغير وذلك بتقييد المالك الحقيقي للمطالبة بحقه بأجل قصير وأن هذا يعتبر بمثابة إسقاط أسى الحقوق الدستورية ألا وهو حق الملكية وأن ترجيح مصلحة المالك الحقيقي فيه حماية لهذا الحق. وهو ما دفع البعض⁷¹⁴ للقول بأن المادة الثانية تشكل إحدى الثغرات التشريعية التي تمكن بعض الأشخاص من الاستلاء على عقارات الغير دون موجب قانوني بالإضافة الى إلقاء العبء على المالكين المقيدون بضرورة الاطلاع على وضعية عقاراتهم على الأقل مرة كل أربع سنوات. لكن ما يمكن قوله هو أن المشرع المغربي من خلال هذه المادة حاول جاهدا التوفيق بين المالك الحقيقي والغير الذي قيد حقه بالرسم العقاري وكان ضحية تدليس أو تزوير أو استعماله والذي كان جديرا بالنقد هو الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري الذي اعطى الحماية المطلقة للغير حسن النية دون أن يلتفت للمالك الحقيقي، بل الأكثر من ذلك هناك من اعتبرها قد "أصابت الرسم العقاري في مقتل" وأنه وقع اهتزاز مبدأ القوة الثبوتية للرسم العقاري وهو من النظام العام، وتبعاً لذلك سيمتاز النظام الاقتصادي⁷¹⁵.

ومن جملة القرارات القضائية التي تسير في هذا الاتجاه القرار عدد 1107 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/03/2008 في الملف المدني عدد 06/1638⁷¹⁶: "حسن نية المشتري طبقاً للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري لا أثر له على ما تمسك به الطاعنة من زورية العقد ما دام أن تبوؤ الزورية يجعله منعماً غير منتج لأي أثر، وإن كان مسجلاً بالرسم العقاري حتى ولو كان المشتري حسن النية". قرار عدد 3009 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 يونيو 2011 في الملف المدني عدد: 45/1/1/2010 "مادامت المحكمة الجنائية قضت بإتلاف العقد المزور سند التملك فإن هذا العقد المؤسس عليه عقد البيع يصبح منعماً ولا مجال لاعتبار حسن نية المشتري في دعوى تسجيل شرائه بالرسم العقاري، إذ أن ما بني على باطل فهو باطل". قرار عدد 4285 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/10/2010 في الملف عدد 09/266: "لا تعقد المحكمة بحسن النية المنصوص عليها في الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري إذا تبين لها أن سند التملك الطاعنين باطل لتأسيسه على عقد مزور".

(714) ادريس الفاخوري، الوسيط في نظام الملكية العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية والتشريعات العقارية الخاصة، الطبعة الثالثة 2019، ص 137. ثم انظر عائشة أمغار، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان: الاستيلاء على عقارات الغير وأثره على الأمن العقاري، سنة 2018/2019 ص 105.

(715) للتعلم أكثر أحيلكم على مؤلف الأستاذ أحمد ادريوش، ضمن سلسلته تأملات نظرية حول مدونة الحقوق العينية، الكراسة الثانية: إشكالية التوفيق بين استقرار المعاملات وبين حماية الملكية العقارية: دراسة حول أصل وأصالة المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، مطبعة الأمانة الرباط، الطبعة الأولى، 2013/2014، ص 39 وما يليه.

(716) منشور ضمن مؤلف مناهج القانون العقاري المعمق، للأستاذ الدكتور أحمد ادريوش، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مكتبة دار السلام، الإصدار رقم 41، 2023، ص 318.

قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الغرفة المدنية⁷¹⁷: "حيث إن العقد هو عقد تبنت زورته بحكم جنحي حائز لقوة الشيء المقضي به حسب الثابت من أوراق الملف وهو عقد باطل، وعملا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، فلا مجال للاستدلال بحسن النية".
قرار عدد 269 صادر عن محكمة النقض مؤرخ في 2009/01/21 ملف مدني عدد 2007/1/1/1877⁷¹⁸

هذا ما يتعلق بالقضاء المغربي فماذا عن موقف الفقه الإسلامي؟
من خلال العديد من الشروح نجد أن الفقه الإسلامي بدوره سلك نفس اتجاه القرارات السابقة الذكر، فقد جاء في شرح الشيخ الشثري لمنظومة القواعد الفقهية للسعدي: "إذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع"⁷¹⁹. وهي ما عبر عنها بعض الفقهاء بأن ما بني على فاسد فهو فاسد"، أو "ما بني على باطل فهو باطل". ويقابله في القواعد القانونية "بطلان الالتزام الأصلي ينتج عنه بطلان الالتزام الفرعي". وفي هذا السياق قال شرف الدين العمري الشافعي في نظمه للورقات: "فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبي"⁷²⁰

وعليه يمكن القول إن القرارات القضائية السالفة الذكر وغيرها الذي سايرتها في نفس المنحى ما هي إلا خروجاً عن القاعدة القانونية واستثناء من الفصل 66 من ظ ت ع، وهي ما دفعت المشرع للتدخل لتكريس هذه الاجتهادات القضائية بمقتضى قانوني وهو المادة الثانية من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. وعليه فالأصل هو عدم التمسك بإبطال أي تقييد في الرسم العقاري في مواجهة الغير المقيد حسن النية بمعنى ترجيح مصلحة الغير المقيد عن حسن النية وهو ما استقر عليه القضاء في بعض قراراته سنعرضها من خلال الاتجاه الثاني.

الاتجاه الثاني:

ترجيح مصلحة الغير حسن النية

إن تقييد الغير حسن النية حقا عينيا بالرسم العقاري يجعلنا نفترض فيه بأنه صاحب الحق الحقيقي وبالتالي يكون للحق الذي تم تقييده حجية في مواجهة الأغيار؛ وهنا تكمن الحماية الأولى التي أقرها المشرع للغير المقيد عن حسن النية وذلك لغاية تتجلى في استقرار المعاملات.
نص المشرع في الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 كما عدل وتمم بالقانون 14-07⁷²¹ "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في

717 (قرار لمحكمة النقض منشور ضمن مؤلف مناهج القانون العقاري المعمق، للأستاذ الدكتور أحمد ادريوش م.س. ص.324

718 (قرار لمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) منشور ضمن مؤلف مناهج القانون العقاري المعمق، للأستاذ الدكتور أحمد ادريوش م.س. ص.321

719 (سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية، دار اشبيليا للنشر والتوزيع، 1424 هـ / 2003 / 2004.

720 (نظم الوراثة للشيخ شرف الدين العمري الشافعي، باب أصول الفقه، رقم 11
721 (الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون 14 : 07.

الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية. لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة".

وفي نفس الإطار نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية⁷²² "أن ما يقع على التقييدات من ابطال او تغيير او تشطيط من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب ابطاله أو تغييره أو التشطيط عليه". من خلال هذين النصين، يتبين أن المشرع قد أخذ بمبدأ الأثر الانشائي للتقييد بالرسم العقاري، بحيث استلزم إشهار جميع التصرفات القانونية الواردة على العقارات المحفوظة بالسجلات لدى المحافظة العقارية حتى تكتسب تلك الحقوق حجيتها وترتب آثارها القانونية خاصة تجاه الغير حسن النية، حيث أن حجية القيد بالنسبة له تتجلى في صورتين: صورة ايجابية وصورة سلبية. فالصورة ايجابية تعني أن كل ما هو مسجل في السجل العقاري يعتبر قائماً وصحيحاً بالنسبة للغير الذي اكتسب حقه بالاستناد لهذه القيود، أما الصورة السلبية فتعني أن كل ما ليس مقيداً في السجل العقاري يعتبر غير موجود بالنسبة للغير الذي اكتسب حقه بالاستناد لبيانات هذا السجل التي لا تنص على التكليف أو الحق الذي يراد إلزامه به. إذن فالغير الذي وثق بما هو مضمن بالسجلات العقارية والشواهد المستخلصة منها، قد وثق بظواهر الأمور وبما هو مقيد بالرسم العقاري وتعامل مع المتعاقد معه كأنه هو المالك الحقيقي وتعاقد على ذلك الأساس، هذا الغير ضمن له المشرع حماية مطلقة وبالتالي لا يمكن أن يبطل أو يشطب على ذلك التقييد التابع لإنشاء الرسم العقاري

كما أن مقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري منحت حماية مطلقة للغير المقيد حسن النية بحيث تكون الحقوق العينية المقيدة على عقار محفظ لها الحجية في مواجهة الأغيار ولا يمكن لأحد بمن فيه المالك الحقيقي التمسك ببطلائها، كما أن المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، التي جاءت كبديل للفصل 3 من ظهير 1915 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفوظة، وإن كانت قد أعطت حماية نسبية للغير المقيد عن حسن النية خلال مدة أربع سنوات، فهي تصبح بمرور هذه المدة مطلقة في حالة ما لم يطالب المالك الحقيقي للعقار بحقه خلال هذه المدة.⁷²³

ومن بين القرارات التي ذهبت إلى ترجيح مصلحة الغير حسن النية:

قرار عدد 1/170 صادر عن محكمة النقض بغرفتها المدنية (القسم الأول) والتجارية (القسم الثاني) بتاريخ 20/03/2013 في الملف المدني عدد 2012/1/1/2820⁷²⁴ إن تبوؤ التزوير في عقد وقع تقييده بالرسم العقاري لا يمكن أن يكون سبباً لإبطال التقييدات اللاحقة مادام أن الأصل في تقييد

(722) ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

(723) محمد بن الحاج السلمي، سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري والتحفيز الاجتماعي الاقتصادي، منشورات عكاظ الرباط 2002 ص 170

(724) قرار محكمة النقض بغرفتها المدنية (القسم الأول) والتجارية (القسم الثاني) قرار عدد 170/1 بتاريخ 20/03/2013 في الملف المدني عدد 2012/1/1/2820 منشور ضمن مؤلف مناهج القانون العقاري المعمق، للأستاذ الدكتور أحمد ادريوش، م س، ص 331

التصرفات والحقوق في الرسوم العقارية هو قرينة حسن النية على صحتها لفائدة الغير ما لم يثبت خلاف ذلك".

من خلال هذا القرار، حاولت محكمة النقض الانتصار لمسألة حماية المقيد بحسن نية حيث أقرت أن هذا الغير يكتسي تقييده حجية مطلقة في مواجهة الكافة منذ تاريخ قيده بالسجلات العقارية، لأن تسجيل الحقوق والتصرفات في الرسوم العقارية يعتبر قرينة لفائدة الغير حسن النية على صحتها ولو تعلق الأمر بطلب التشطيب للتزوير.

رغم أن مقتضيات هذا القرار غير مستساغة بكثرة على مستوى الاجتهاد القضائي، إلا أن تكريس مثل هذا القرار يحقق استقرار المعاملات العقارية، لذلك يتعين تكميم المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية بما يفيد إعطاء مفهوم ضيق للتزوير واعتباره ضابطاً يدل على سوء النية إذا ارتكبه المقيد أما إذا كان مرتكباً من قبل المالك الأصلي للعقار أي المفوت، فهنا تجب مراعاة المقيد حسن النية الذي يعتبر غيراً أجنبياً – عن العقد المبرم بين المالك الأصلي للعقار والمفوت له غير المقيد- ولا دخل له في الجريمة وهو الأولى بالحماية.

الاتجاه الثالث:

وهو القرار قيد التعليق وهو عبارة عن محاولة غير مكتملة لتوحيد الاجتهاد القضائي حسب المادة 84 من قانون التنظيم القضائي⁷²⁵ فمن اختصاصات محكمة النقض هي توحيد العمل والاجتهاد القضائي إذ جاء فيه: "تسهر محكمة النقض باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة على مراقبة التطبيق السليم للقانون، وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي".

والقرار موضوع التعليق الصادر عنها، جاء بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وإيجاد حل لمسألة الأولى بالحماية هل المالك الحقيقي للعقار، أم الغير الذي قيد حقه بالرسم العقاري بحسن النية. إلا أن ما ناقشته محكمة النقض في هذا القرار هو المعيار الذي من خلاله يمكن القول بوجود سوء النية من عدمها.

بعد أن استقر القضاء سابقاً على أن الغير سيئ النية هو الذي كان يعلم عيوب سند سلفه، أي معيار العلم سواء اقترن بالتواطؤ أم لا، فإن محكمة النقض من خلال هذا القرار قد أضافت معيار آخر للقول بوجود سوء النية، يتمثل في مجرد إمكانية علم الغير بالعيوب والشوائب.

بهذا التوجه تكون قد نحت منحى آخر وهو توجه محمود على اعتباره أنه وسع من مفهوم الغير سيئ النية.

لكن إذا ما سلمنا بهذا التوجه، فيطرح أمامنا تساؤل عن القرائن التي من خلالها يمكن القول إن الغير كان بإمكانه أن يعلم عيب سلفه؟ وهل القرائن التي اعتمدها هذا القرار تعتبر كافية؟ بالرجوع إلى حيثيات القرار، نجد أن محكمة النقض قد اعتمدت على قرائن متعددة للقول بأن الطاعن كان بإمكانه أن يعلم العيب الذي يشوب المبادلة المستند عليها في التملك من طرف البائع،

(725) ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

من بينها أن الطاعن مقاول ويتاجر في العقارات ويفترض فيه الحذروغيرما سبق ذكره بالتفصيل في ملخص الوقائع.

ما يمكن ملاحظته في هذا القرار أن محكمة النقض استبدلت علة قرار محكمة الاستئناف المنتقدة بعلّة قانونية أخرى، وهي بذلك تكون خرجت عن وظيفتها التقليدية وهي ممارسة الرقابة على محاكم الموضوع فيما يخص حسن تطبيق القانون.

عموماً يمكن القول إن قرار محكمة النقض موضوع التعليق الرامي إلى رفض الطلب كان قراراً صائباً يستحق التأييد ، و من شأن هذا القرار أن يؤثر إيجابياً على مسار العمل القضائي من أجل التصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات، وحماية المالك الحقيقي للعقار، على الرغم من أنه لم يجد حلالاً للإشكالية الأساسية المتمثلة في الأولى بالحماية وبعبارة أخرى "التوفيق بين حماية المالك الحقيقي للعقار والغير المقيد عن حسن النية في الرسم العقاري"، على اعتبار أن الغير في هذا القرار سيء النية وثابتة بقرائن متعددة، إذ لا سبيل للحديث عن حسن النية في علاقته بالمالك الحقيقي، وبالتالي يمكن اعتباره محاولة غير مكتملة لتوحيد الاجتهاد القضائي حول هذه الإشكالية.